

1524908-13.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... chão. Responde a outro processo por narcotráfico. Não conhecia os guardas. Não recebe todos os cuidados para suas condições de saúde. Na polícia, disse que recebeu a droga para transporta-la, e iria devolver horas depois em troca de uma pedra de crack para consumo próprio. Já foi preso e processado por narcotráfico. Disse se encontrar em situação de rua. A denúncia procede. As testemunhas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524908-13.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1524908-13.2021.8.26.0228

Controle nº 1362/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERSON DO NASCIMENTO

Aos 16/03/22, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, por meio virtual, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, presencialmente no fórum, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu VANDERSON DO NASCIMENTO e a sua defensora, Dra. Virgínia Sanches Rodrigues Caldas Catelan, Defensora Pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A ação é procedente, uma vez que os fatos narrados na inicial restaram bem comprovados diante das provas produzidas nos autos. De fato, os policiais ouvidos nesta data afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina pela região da "cracolândia" quando avistaram o réu, que saía do "fluxo" (o aglomerado de usuários de entorpecentes que se reúne na cracolândia), com uma bolsa na mão. Ao se aproximarem, o réu correu de volta em direção ao "fluxo" e jogou a bolsa ao solo. Os policiais o detiveram e a bolsa foi recuperada, dentro da qual encontraram o entorpecente apreendido, além de um celular e um documento em nome de terceiro sendo que o acusado afirmou que a droga pertencia a terceiro. Ao ser interrogado na fase policial, o réu afirmou que a bolsa que carregava não era sua, mas que um tal de "Neguinho" havia pedido que a segurasse por um tempo em troca de uma pedra de "crack", sendo que desconhecia seu

conteúdo. Ao ser interrogado em Juízo, o acusado admitiu a prática do delito. O laudo toxicológico juntado aos autos comprovou a materialidade do delito. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que VANDERSON DO NASCIMENTO seja CONDENADO nos termos da denúncia, aplicando-se base em seu mínimo legal, por ser tecnicamente primário, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento, tendo em vista que responde a outro processo pela prática de tráfico de drogas. Pela defesa foi alegado, em síntese: Preliminarmente, requer a Defesa o reconhecimento da nulidade processual em virtude da existência da prova ilícita. Consoante se extrai da exordial acusatória, no dia em questão, o acusado estava em via pública quando foi abordada por GUARDAS CIVIS, os quais resolveram abordá-lo e revistá-lo, em típica atividade de investigação policial. É sabido que Guardas Municipais não podem fazer abordagens e revistas em pessoas que transitam nas ruas, uma vez que limitados constitucionalmente para a realização de guarda do PATRIMÔNIO PÚBLICO. Estabelece a Constituição, em seu art. 144, que a segurança pública é exercida pelos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpo de bombeiros. Dentre estes, teria a polícia civil as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais (§4o) enquanto à polícia militar está reservada a função de realizar o patrulhamento ostensivo e a preservação da ordem pública (§5o). Das guardas civis municipais, trata o art. 144, §8o que dispõe "os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". (grifos e sublinhados nossos). Verifica-se, portanto, que no texto Constitucional está delineado de maneira evidente que a Guarda Municipal não tem como função exercer o policiamento ostensivo, atender denúncias anônimas ou revistar pessoas, atribuições que são típicas de outros órgãos, cabendo-lhe tão-somente a proteção de seus bens, serviços e instalações. Registre-se que não se está negando o direito garantido a toda e qualquer pessoa, o que inclui os guardas municipais, de realizar a prisão de qualquer um que seja flagrado praticando crime. Contudo, guardas municipais não podem, abordar e revistar pessoas para verificar se praticaram ou estão praticando algum crime. E no caso que tratamos aqui, não houve prisão em flagrante e depois busca pessoal com a apreensão das drogas, o que poderia estar respaldado pelo art. 301 do Código de Processo Penal, mas ao contrário, primeiro houve um "patrulhamento ostensivo", com posterior abordagem "de rotina", sob a alegação de que o acusado estaria em atitude suspeita. O que está respaldado pelo art. 301 do Código de Processo Penal é que "qualquer do povo" pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e não que, qualquer do povo, o que inclui guardas municipais, pode abordar e revistar pessoas para verificar se ela está ou não em situação de flagrância. Assim, se guardas civis metropolitanos não podem investigar e apurar eventuais ilícitos criminais, a prisão em flagrante do acusado deve ser considerada ilegal, nos termos do art. 144, seus incisos e §8o da Constituição Federal. Ante todo o exposto, como a prisão do acusado foi realizada por Guardas Civis Metropolitanos que estavam em situação que exorbitou em muito suas funções constitucionais, a única conclusão possível é da ilegalidade da prisão em flagrante e de todo o processo que dela decorreu, sendo forçosa a declaração da nulidade, "ab initio", que conduzirá à nulidade do feito ou à absolvição do acusado pelo art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Caso assim não entenda, imperioso reconhecer, na espécie, que, ao cabo da instrução processual, o respeitável Órgão Acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude do que a absolvição da acusada é medida de rigor. O acusado confessou a prática delitiva, assim como já havia feito em sede inquisitorial. Sustentou ser usuário e que foi oferecido transportar a droga em troca de UMA PEDRA DE CRACK (p. 7) e em razão do seu vício não conseguiu negar. Consta do interrogatório e de foto de fls. 32 que o acusado claramente estava em situação de rua. Consta ainda do depoimento do primeiro GCM que o acusado inclusive estava desorientado quanto ao tempo e aparentemente sob efeito de alguma substância. Como se vê, nesta situação, era inexigível do acusado agir conforme as normas e o direito, pois se encontrava em situação à margem de proteção que esse sistema ficcional pressupõe. Cumpre observar que, ainda que não se considere devidamente comprovada a existência de tal

excludente, há, no mínimo, dúvida razoável quanto à sua presença, pelo teor do interrogatório e pelo depoimento das testemunhas, o que já autoriza a prolação de um decreto absolutório, dada a redação expressa e inequívoca do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Caso seja necessário infligir penas, a defesa roga sejam elas estipuladas na base mínima, pois favoráveis as circunstâncias judiciais. Em terceira etapa da dosimetria solicita-se a aplicação do redutor legal previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 em seu máximo, eis que o acusado é primário, de bons antecedentes e sem provas de que possua qualquer envolvimento com organizações criminosas. Inexiste nos autos qualquer investigação nesse sentido, sequer há o registro de eventual denúncia anônima. Os policiais não se aprofundaram nas investigações, assim como o órgão acusatório. Logo, não é possível supor que o acusado seria integrante de organização criminosa, máxime porque é primário e de bons antecedentes. Em suma, requer: A) a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; B) na remota hipótese de improvimento do pedido absolutório, b.1) sejam estabelecidas penas-base no patamar mínimo legal, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais; b.2) seja aplicada, em terceira fase da dosimetria da reprimenda, a causa de diminuição de penas prevista no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, em sua máxima fração (2/3); b.3) fixada a pena privativa de liberdade em patamar igual ou inferior a quatro anos de reclusão, haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, declarando-se, por conseguinte, a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44, caput, da Lei nº 11.343/06 ('...vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos...'), bem como da parte intermediária do §4º ao artigo 33, da mesma lei ('...vedada a conversão em penas restritivas de direitos...'), com fixação do regime de cumprimento das reprimendas de modo compatível com a providência supra. b.5) seja permitido aguardar ao trânsito em julgado em liberdade. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. VANDERSON DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, transportava e trazia consigo um invólucro contendo pedras de "crack" (cocaína), com peso líquido de 57,9 g (cinquenta e sete gramas e nove decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante. Notificado, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi o réu citado e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi então interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do imputado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu as teses e os benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença, eis que nulidade alguma existiu. Os guardas não investigaram ou se comportaram como policiais. Qualquer do povo pode, enquanto os agentes da lei devem agir

em caso de violação da lei, mormente penal. Demais disso, exsurge dos autos que não houve alguma revista pessoal no réu, mais ainda sem motivação. Ao contrário, o imputado viu os guardas e, nervoso, desfez-se da sacola que continha a droga. Ora, os guardas apenas, vendo tal cena, foram verificar o que existia na tal sacola. Observando que nela havia entorpecentes, em quantidade bastante razoável, detiveram o réu. Assim, agiram estritamente nos limites da lei. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para cocaína, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida pelo réu, para fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, o réu disse que está em situação de rua há seis anos, e atualmente estava na região conhecida como "cracolândia". Disse que não tem familiares a quem recorrer. Anotou que usa droga e é soropositivo para HIV, desde que nasceu, transmitido por sua mãe. Relatou que um usuário lhe pediu para transportar a droga e lhe prometeu dinheiro pelo transporte. Foi parado pelos guardas e, assustado, jogou a sacola com as drogas no chão. Responde a outro processo por narcotráfico. Não conhecia os guardas. Não recebe todos os cuidados para suas condições de saúde. Na polícia,

disse que recebeu a droga para transporta-la, e iria devolver horas depois em troca de uma pedra de crack para consumo próprio. Já foi preso e processado por narcotráfico. Disse se encontrar em situação de rua. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, ouvidas em juízo, relataram que na região conhecida como "cracolândia", viram o réu saindo do fluxo com bolsa a tiracolo. Ao notar os guardas, voltou ao fluxo de pessoas e arremessou uma bolsa. Essa foi apreendida e nela havia porção de crack. Francisco continuou dizendo que o réu anotou que transportava a drogas para terceiro, sendo uma pedra, como uma grande porção. O réu não lhe disse que era usuário. Não parecia sujo ou morador de rua. Pareceu-lhe estar sob efeito de alguma substância, mas não pode dar certeza. Antônio disse que na bolsa também estavam um celular e documento de uma mulher, bem como que o réu lhe disse que a droga era de terceiro, e que receberia dinheiro para transportar a droga. Também não notou o réu com aspecto de morador de rua. Não lhe pareceu que o réu estivesse sob efeito de droga. A condenação é de rigor, diante do conjunto probatório suficiente, a indicar que o réu trazia drogas para o comércio ilícito. As testemunhas ouvidas, outrossim, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. Essa prova é toda no sentido de que o réu transportava droga para o comércio ilícito de entorpecentes, tanto assim que se tratava de porção grande de narcótico, certamente para fracionamento posterior. Demais disso, ganharia dinheiro para tal transporte, e é isso que disse o réu em juízo, acompanhado por testemunha. Esta disse que o réu não se disse usuário no momento em que detido, e que não aparentava, como os demais, ser morador de rua. Uma das testemunhas ainda relatou que não lhe pareceu estar o imputado sob efeito de droga, quando da abordagem. O imputado é que não se acertou em suas palavras, eis que, ouvido na fase policial, nada falou em dinheiro, mas sim em ganhar apenas uma pedra de crack para o tal transporte ilícito de entorpecentes. Não se deve olvidar de que o réu já é processado em outro caso de narcotráfico. A despeito de eventualmente ser usuário de droga, tal fato não descaracteriza a possibilidade, colocada como certa no presente feito, de também atuar no narcotráfico transportando droga para o comércio ilícito de substância entorpecente. Daí porque inviável dizer sobre caracterização de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, cujos elementos não estão postos no caso concreto. Não se pode acolher como escusa de prática de crime grave o fato de eventualmente ser usuário do entorpecente, acabando por se envolver no próprio narcotráfico. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicada, posto ser o caso do ora imputado. A redução deve se dar no patamar máximo de lei, pois a quantidade de drogas é pequena, ainda que não mínima. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, perfazendo pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Na segunda fase de fixação de sanção, deveria a pena ser aumentada de três meses em virtude do crime praticado em pleno período de declaração de calamidade pública, bastando sua aplicação, pela letra da lei, que a prática delitiva ocorra nesse período, o que já indica grande desvalor da conduta, além de estar intrínseco o aproveitamento dessa situação para o cometimento da infração penal, desnecessitando outras demonstrações probatórias. Ocorre que compenso o aumento com a atenuante da confissão, restando a pena inalterada. Por fim, reduzo a sanção do patamar já indicado, em razão da primariedade, com pena final de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu VANDERSON DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa no valor unitário mínimo legal. Diante do cancelamento da súmula 512 pelo E. STJ, em consonância com decisão plenária do E. STF, que julgou ausente o

caráter de hediondez do delito do tráfico chamado privilegiado, quando o §4º do artigo 33 é aplicado, resta no caso presente afastado o caráter de hediondez do delito. Outrossim, em cumprimento à decisão em HC (596.603-SP), com abrangência de coletivo, proferida pelo E. STJ, vedada a imposição de regime fechado (ainda que inicial) a casos como o presente, de tráfico privilegiado, em que se aplicou o §4º do artigo 33, da Lei Antidrogas, e dessa forma afastado eventual entendimento do juízo por regime prisional inicial mais severo, imponho o regime aberto para o início do cumprimento de pena, desde logo, mais uma vez atento ao referido HC coletivo, eis que em tal r. decisão consta a determinação de imposição de regime aberto em casos como o presente, em que a pena mínima, com a redução máxima pertinente, foi imposta. Por tal motivo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária que fixo em um salário mínimo, dirigido a instituição com destinação social, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais. Poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Transitada em julgado, resta o réu ciente de que deverá recolher pena de multa em dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes e o réu por intimados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que as partes saíram intimadas da r. Sentença. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.